

1500877-81.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... ter firmado o entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500877-81.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500877-81.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2296965/2021 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 21132616 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1485/21/925 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2296965 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1485/21/925 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2296965/2021 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA (com qualificação à fl. 15) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 30/10/2021, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 30 de outubro de 2021, por volta de 01h00min, na Rua Jorge Juventino de Aguiar, nº 265, Conjunto Habitacional Roberto Romano, nesta

cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA, qualificado a fls. 12, trazia consigo, para fins de comercialização, 83 microtubos contendo cocaína, com peso aproximado de 53 gramas, e 58 porções de maconha, pesando aproximadamente 60 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06, auto de constatação preliminar de fls. 13 e laudo de exame químico toxicológico definitivo a fls. 60/62), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 66/67); 2) o recebimento da denúncia (fls. 104/105) em 08/03/2022; 3) a defesa (fls. 102/103); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 7/8, 11/12). Anoto, a concessão da liberdade provisória de DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA nesta fase processual (fls. 51/53).

Em audiência (fls. 145/146), foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes. Homologado o pedido da defesa quanto a oitiva da segunda testemunha.

Ocasião em que, redesignou-se a audiência.

Em nova audiência, foi ouvida a segunda testemunha, tendo sido o acusado interrogado, em seguida. Encerrada a instrução, em debates, o Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a condenação do réu, pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Quanto a dosimetria, pleiteou o aumento da pena base em virtude da variedade de drogas e o afastamento do redutor em virtude da quantia de droga e dinheiro, e do local de vendas, indicar sua ligação com o crime organizado.

A defesa, por sua vez, pediu a improcedência da ação, alegando que as testemunhas de acusação não conseguiram comprovar a culpa do réu.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 4); boletim de ocorrência (fls. 5/6); auto de exibição e apreensão (fl. 9); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 16); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 63/65).

2.2. Da autoria.

A autoria de DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 7/8, 11/12 e 144), ao auto de exibição e apreensão (fls. 9), aos laudos periciais (fls. 63/65) e à prova oral colhida em audiências, infere-se o seguinte panorama: "na madrugada dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Conjunto Roberto Romano, oportunidade em que, ao passarem pelo bloco 265, situado na Rua Jorge Juventino de Aguiar, avistaram o denunciado correndo e pulando um muro. Diante disso, os agentes públicos iniciaram breve acompanhamento e alcançaram o denunciado, abordando-o. Submetido a busca pessoal, na posse de DAVI RAFAEL foi localizada uma sacola plástica com 83 microtubos contendo cocaína e 58 porções de maconha. Ainda, no bolso da bermuda do denunciado foi apreendida a quantia de R\$91,00, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante."

Nesse sentido, as testemunhas Walter e Maik, ambos policiais militares, em sede policial asseveraram que: "estava em patrulhamento pelo Bairro Conjunto Roberto

Romano. Ao passar defronte ao bloco 265 sito na Rua Jorge Juventino de Aguiar, observou um indivíduo se evadindo correndo e pulou um muro. O mesmo foi acompanhando e detido na posse de uma sacola plástica que continha em seu interior 83 micro tubos contendo cocaína e 58 invólucros contendo maconha. O indivíduo foi identificado como sendo DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA e após ser submetido a uma busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda R\$ 91,00 em espécie. Indagado sobre a droga David confessou que é de sua propriedade e estava realizando a venda. Face aos fatos o mesmo o depoente apresentou o acusado no plantão policial onde a Autoridade Policial ratificou a prisão, autuando-o por infração ao Artigo 11.343/06, permanecendo o mesmo recolhido a disposição da justiça."

Em audiência, a testemunha Walter, ratificou a essência da versão, apenas acrescentando que era comandante da operação e que seu companheiro Maik poderia colaborar com maiores detalhes acerca dos fatos, devido sua participou efetiva na captura do acusado.

Da mesma forma, a testemunha Maik disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento nas imediações do Conjunto Romano e o réu foi visto tentando se evadir das viaturas que estavam pelo bairro. No momento ele e seu colega desembarcaram da viatura e o depoente tentou correr, pulou um ou dois muros, até que no terceiro muro escorregou e o depoente conseguiu contê-lo, algemá-lo, e recolher o saco plástico que continha as drogas e estava com o réu. Questionado no dia da ocorrência o próprio réu assumiu que estava traficando. Diante dos fatos foi algemado e conduzido até o plantão policial. Recorda-se que o réu estava com maconha e cocaína, e cerca de 90 ou 100 reais em dinheiro. O local ali é muito conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Diz ser difícil precisar, mas que os indivíduos ali são organizados pois a viatura nem adentrou o bairro e os indivíduos começam a dispersar, correr, é possível visualizar de longe que no momento que a viatura entra no bairro já começam a correr. Acredita ser provável que o réu já tenha iniciação no crime pois não é de praxe quem está ali estar vendendo pouca quantidade, pela intensidade da venda no local.

Por sua vez, o acusado David Rafael Birollo Ferreira, em solo policial (fls. 11/12), confessou a prática do crime. Relatou: que nesta data estava no bloco 265 do Conjunto Habitacional Roberto Romano, oportunidade em que foi abordado por policiais militares, antes de ser abordado tentou evadir-se correndo porém sofreu uma queda e foi detido. Na sua posse os militares localizaram 58 porções de maconha, 83 micro tubos contendo cocaína e R\$ 91,00 em dinheiro. O interrogando alega que a droga encontrada consigo é de sua propriedade e estava realizando a venda no local. Vende cada porção de cocaína e de maconha por R\$ 14,00.

Em audiência, modificou sua versão e disse que é usuário, contou que no dia foi comprar drogas para seu consumo, e quando viu as viaturas saiu correndo por susto e foi pego pelo policial, mas que nenhum dos entorpecentes era seu e teriam sido encontrados próximo a ele, mas não com ele. Assevera que somente confessou na delegacia pois pressionado pelo policial Maik, que inclusive o teria agredido. Ora, o depoimento apresentado pelos policiais, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Vale dizer ainda que, embora o réu tenha modificado sua versão em juízo, é certo que mesmo na delegacia o réu confessou e inclusive disse que não sofreu qualquer tipo de violência na abordagem (fl. 11-12), não havendo qualquer indício que não só os policiais militares teriam mentido para o incriminar como também os policiais civis fariam parte deste conluio.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram encontrados 83 microtubos contendo cocaína, 58 invólucros contendo maconha e R\$ 91,00 em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, ressalto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a variedade, natureza das drogas e quantidade embora não seja ínfimas, também não é extraordinária.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei

11.343/06 – Lei de Drogas). Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Respeitado o entendimento ministerial, o mero fato de o acusado ter sido preso em local conhecido pelo alto fluxo de tráfico de droga não faz presumir que ele integre organização criminosa, devendo haver prova concreta nesse sentido para que se obste a incidência da benesse, sobretudo porque o réu é primário e de bons antecedentes e a quantia de droga e dinheiro apreendidas não se mostram exorbitantes.

No mais, a redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, levando-se em conta a variedade de droga apreendida com o réu "maconha" e "cocaína", tenho que a redução deva ser feita pela metade, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e as condições pessoais do condenado e, ainda, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo artigo 59, sendo que o condenado não é reincidente, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c" e parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, fixo, para início do cumprimento da pena, o regime aberto.

Esclareço que o regime em tela é cabível em razão de o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, ter firmado o entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP)

Deixo de realizar a detração nesse momento porque, em vista do regime aplicado não veria alteração.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP)

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, com fundamento, principalmente, na garantia constitucional da individualização da pena, declarou inconstitucional a vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos aos condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (HC 97256/RS, Rel. Min. Ayres Britto).

Considerando o montante de pena aplicado, que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis e ademais que o delito não foi cometido com grave ameaça ou violência, verifica-se a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritiva de direitos. Pelo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, em busca do resgate da autoestima e aptidão para o trabalho da apenada, devendo o Juízo da execução, em audiência admonitória, definir a entidade que será beneficiado com a prestação social alternativa e prestação pecuniária no valor correspondente a 1(um) salário mínimo, a ser pago à entidade a ser definida pelo juízo da execução, admitindo-se o parcelamento, conforme a situação financeira do réu.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP):

Resta prejudicado o sursis em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP)

Considerando e a situação socioeconômica do sentenciado, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser reajustado a partir da data da prática do crime. A pena de multa deverá ser paga nos termos e nos prazos dispostos no artigo 50 do CP, sob pena de execução.

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra DAVID RAFAEL BIROLLO FERREIRA (com qualificação à fl. 15), por haver incorrido nas sanções art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito de prestação de serviços e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação.

Considerando a primariedade do réu, o montante de pena aplicado, o regime inicial fixado e a substituição da pena, o réu poderá apelar em liberdade.

Quanto ao dinheiro apreendido, DECRETO a sua perda em favor da UNIÃO, devendo o valor ser recolhido em favor do FUNAD.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA